

1501240-76.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... dinheiro. Ele confessou que estava realizando trafico desde as dez horas e que não tinha local fixo, ficava rondando. Eu não o conhecia anteriormente e não sei se o local era ponto de trafico.

Em Juízo, o réu confessou os fatos. Disse que estava traficando, pois tinha muita conta para pagar.

Como se vê, a confissão do acusado vem corroborada com os depoimentos dos guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501240-76.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501240-76.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138826/2022 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 25116116 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2138826 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2138826 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ANGELINO SELZZO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LEANDRO ANGELINO SELZZO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 21 de maio de 2022, por volta de 20h, na Av. João XXIII, altura do nº 3.247, Jardim São Pedro, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de serviço e reinserção social (CRAS), e de estabelecimento de ensino e de entidades sociais e beneficentes (CERIM Horária de Lima Barbosa, Ministério Cristão Família

Projeto de Deus e Comunidade São Francisco de Assis), trazia consigo, para fins de tráfico, 14 porções de tetraidrocanabinol – THC (maconha), com peso de 12,87g, 23 porções de crack, com peso líquido de 3,54g, e 25 porções de cocaína em pó, com peso de 19,07g, sem autorização legal ou regulamentar.

Aditamento da denúncia à fls. 129

Recebimento da denúncia e seu respectivo aditamento em 08 de julho de 2022 (fls. 131).

Citado (fls. 138), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 141).

Prosseguiu-se a instrução processual, eis que ausente causa de absolvição sumária, nos termos da decisão às fls. 100/101 (fls. 142).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e interrogatório do réu por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Preliminarmente, a ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais deve ser afastada, porquanto, considerando que o acusado carregando uma bolsa, tentou se esquivar da viatura da Guarda Municipal, levantou a suspeita das autoridades, e quando indagado, prontamente confessou o delito.

Cumpra ressaltar que a prisão em flagrante conduzida por Guardas Municipais não possui qualquer vício, pois é admitida em Lei no art. 301, do Código de Processo Penal e, também, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda que a prática seja desvinculada da atitude de proteção ao patrimônio municipal.

Confira-se AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agrado regimental desprovido (STJ. AgRg no HC 667.413/SP. Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 15/06/2021 – g.n).

No mesmo sentido: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRADO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). 2. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexiste irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agrado regimental improvido. (AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 – g.n)

Não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição de apreensão de fls. 13/14, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 109/111, 112/115, 116/118 e 119/122, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Em Juízo, as testemunhas Evanilson de Oliveira Pinto e Charles Rodrigo Camargos, guardas civis municipais, disseram que a equipe estava em deslocamento para patrulhamento no CRAS de César de Souza. O acusado, ao ver a viatura, mudou de direção, o que causou suspeita na viatura. Abordado, o réu tinha uma bolsa pendurada. Ele de pronto confessou. Encontramos com ele drogas e dinheiro. Ele confessou que estava realizando tráfico desde as dez horas e que não tinha local fixo, ficava rondando. Eu não o conhecia anteriormente e não sei se o local era ponto de tráfico.

Em Juízo, o réu confessou os fatos. Disse que estava traficando, pois tinha muita conta para pagar.

Como se vê, a confissão do acusado vem corroborada com os depoimentos dos guardas civis municipais.

Salienta-se que os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente. A circunstância de serem guardas civis não desmerece seus testemunhos, nem o tornam suspeitos, pois são comprometidos na forma da lei.

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, basta que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Sobre o tema, é expressiva a jurisprudência: "Ressalto que não se faz necessária à mercancia para que se configure o delito em tela. O crime de tráfico de entorpecentes é de múltiplas ações e de perigo abstrato. No caso dos autos, o delito consumou-se pelo simples fato de ter em depósito ou guardar droga. Nessas circunstâncias a mercancia consubstancia mero exaurimento do crime" (TJSP - Apelação criminal nº 911.741.3/0, Rel.: Exmo. Des. FÁBIO GOUVEIA).

Aponto que o acusado foi surpreendido com: a) 14 porções de tetraidrocanabinol - THC (12,87g); b) 23 porções de crack (3,54g); c) 25 porções de cocaína em pó (19,07g), quantidade mais do que suficiente para a realização da mercancia.

Destaca-se que a natureza de duas das drogas apreendidas (crack e cocaína) merece maior reprovação, pois, tratam-se de substâncias entorpecentes que possuem maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública.

Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

Deixo de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, diante da distância entre o local em que o acusado foi preso e os locais de proteção, mais de 100 metros (fls.112/115).

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. (...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda

Turma, julgado em 25/08/2015)

No caso em tela, o acusado é primário (fl.55/56) e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique a atividades criminosas.

Assim, diante do conjunto probatório, conclui-se com segurança, a responsabilidade do acusado quanto ao crime a ele imputado.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, o acusado, primário, foi preso com elevada quantidade e variedade de entorpecentes, devendo a pena base ser aumentada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstancia atenuante da confissão, retorno a pena ao mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls.55/56, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Desta forma, diante do caso concreto e das condições pessoais do acusado, diminuo a reprimenda em 2/3, perfazendo, assim, sanção de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado"(STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime "(STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não

são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO ANGELINO SELZZO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa.

Diante do regime imposto e da quantidade de pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: bolsa e celular (fls. 13/14). Oficie-se.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.13/14).

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, eis que defendido pela Defensoria Pública.

Sentença publicada em audiência.

Mogi das Cruzes, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA